Processo nº 0144334-90.2023.8.17.2001

AUTOR(A): JOSE FABIANO HOLANDA DE SOUSA

RÉU: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA** promovida por José Fabiano Holanda de Sousa em face de Amil Assistência Médica Internacional S.A..

Narra o autor que é titular de um plano de saúde oferecido pela ré e que se encontra adimplente com suas obrigações contratuais. Aduz que foi diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda, se encontrando, à época, internado, necessitando urgentemente do medicamento Xospata 40 mg – 84 comprimidos (Hemifumarato de Gilteritinibe), prescrito por seu médico assistente como essencial para seu tratamento. Segue relatando que, ao buscar a cobertura do plano de saúde para o referido medicamento, a ré negou autorização, sob o argumento de que não constava no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Acrescentou que o orçamento para compra do medicamento resultou em uma quantia de R$ 149.880,00 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta reais), e que não possuía condições financeiras de suportar tal encargo.

Em face de tal estado de coisas, requereu, ao final, em sede de tutela de urgência, que o plano de saúde fosse compelido a custear integralmente o tratamento com o medicamento prescrito pelo médico assistente, bem como sua condenação por danos morais na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Requereu, ainda, os auspícios da justiça gratuita.

Diversos documentos vieram acompanhando a exordial.

Em decisão sob ID nº 151663741, este Juízo concedeu a tutela de urgência pleiteada, bem como a gratuidade de justiça.

Em petição atravessada sob ID nº 153621808, o demandante informou que, ante a demora no cumprimento da liminar e a urgência na ministração do medicamento, desembolsou o valor para compra deste.

Ao contestar (ID nº 154364229), a demandada, Amil Assistência Médica Internacional S.A., preliminarmente, impugnou o valor da causa, afirmando que a quantia atribuída pelo demandante seria exorbitante e não condizia com o objeto da demanda. No mérito, alegou que o

medicamento Xospata não preenche os critérios das Diretrizes de Utilização da ANS, razão pela qual não foi autorizado. Sustentou que atuou de acordo com as normas reguladoras em Saúde Suplementar, não havendo, portanto, qualquer abuso ou ilegalidade em sua conduta. Afirmou, ainda, que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, e que somente seria obrigatória a cobertura de tratamentos fora desse rol, caso houvesse comprovação científica de eficácia ou recomendação de órgãos de avaliação de renome internacional, o que, segundo afirma, não foi comprovado pelo autor.

Determinada a intimação, por este Juízo (ID nº 153890376), para comprovar o cumprimento da liminar, a operadora demandada reiterou os termos de sua contestação, ao mesmo tempo em que informou o falecimento do demandante (ID nº 156660062).

Réplica apresentada em ID nº 162965967, peça na qual é confirmada a informação acerca do falecimento do Sr. JOSE FABIANO HOLANDA DE SOUSA, conforme certidão de óbito anexa, oportunidade na qual seus herdeiros, TATIANE GONÇALVES VIANA DE SOUSA e JOSÉ BENJAMIN FRANCISCO VIANA DE SOUSA, pugnaram pela assunção do polo ativo da presente ação. No mais, reiteraram os termos apresentados na exordial, ao tempo em que impugnaram as teses defensivas.

Determinada a intimação das partes para informar se ainda possuíam provas a produzir (ID nº 167403908), ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Os autos vieram-me conclusos.

É o que há para relatar.

DECIDO.

Julgo antecipadamente o feito, forte na regra estampada no art. 355, I, do CPC.

Antes de se adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise de algumas questões processuais pendentes.

DA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES DO DEMANDANTE NO POLO ATIVO DA PRESENTE AÇÃO

Em réplica apresentada em ID nº 162965967, foi informado acerca do falecimento do Sr. JOSE FABIANO HOLANDA DE SOUSA, razão pela qual seus herdeiros, TATIANE GONÇALVES VIANA DE SOUSA e JOSÉ BENJAMIN FRANCISCO VIANA DE SOUSA, pugnaram por sua habilitação nos autos.

Nos termos do art. 110, do CPC, “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º”. Além disso, o art. 691, do CPC, informa que “O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução”.

No caso dos autos, como dito, houve pedido de habilitação dos sucessores do falecido em réplica, conforme ID nº 162965967, pleito esse que não foi objeto de impugnação pelo demandado quando de sua oportunidade de se manifestar nos autos. Além disso, observo que foi juntada prova documental suficiente a fim de comprovar o vínculo sucessório entre as partes.

No mais, observo, ainda, que o presente pleito não mais possui objeto personalíssimo. É que, pelo que se depreende da petição sob ID nº 153621808, por não ter a demandada cumprido a decisão proferida por este Juízo a tempo, o demandante, quando ainda em vida, precisou desembolsar a quantia necessária para custear o seu tratamento, conforme nota fiscal anexa. Dentro desse contexto, não sendo possível o cumprimento da obrigação principal (caso dos autos,

pois inócuo o fornecimento do medicamento reconhecido em decisão sob ID nº 151663741), esta poderá ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 499, do CPC, tornando-se, portanto, dívida de valor, a qual poderá ser objeto de pretensão pelos herdeiros do falecido.

Pensar de outro modo ensejaria o enriquecimento sem causa da operadora do plano de saúde demandada, no caso de sentença que julgue procedente os pedidos autorais, confirmando a tutela concedida, especialmente quando já houve o desembolso das quantias necessárias para custear o tratamento pleiteado, ante o não cumprimento da decisão antecipatória em tempo hábil para a conservação da integridade física do autor, o qual, ressalte-se, veio a óbito durante o processamento do feito.

Além do mais, houve também pedido de indenização por danos morais na inicial e, consoante Súmula 642, do STJ, tal pleito é passível de transmissão aos herdeiros do demandante: "Súmula 642-STJ: O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória".

Assim sendo, com fundamento nos arts. 110 e 691, do CPC, bem como na Súmula de nº 642, do STJ, **defiro o pedido formulado, possibilitando que os sucessores do Sr. JOSE FABIANO HOLANDA DE SOUSA assumam o polo ativo da presente ação**.

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

O réu, Amil Assistência Médica Internacional S.A., em sua contestação, apresentou impugnação ao valor da causa, argumentando que a quantia atribuída pelo autor é exorbitante e não condiz com o objeto da demanda, solicitando, ao final, a correção do valor da causa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondente ao pedido de indenização por danos morais.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifica-se que o valor da causa foi corretamente estipulado pelo autor, levando em consideração o valor econômico envolvido na demanda. O valor da causa não se limita ao pedido de indenização por danos morais, mas abrange também o custo do medicamento Xospata (Hemifumarato de Gilteritinibe), essencial para o tratamento do demandante, conforme prescrição médica. O orçamento desse medicamento, somado à negativa de cobertura pela demandada e os danos morais pleiteados, representa o real valor econômico da controvérsia, que foi corretamente estimado pelo autor.

Diante disso, não há razão para acolher a impugnação ao valor da causa, pois este foi calculado com base em parâmetros legítimos e em conformidade com o valor econômico da demanda.

Diante do exposto, **indefiro a impugnação ao valor da causa**, mantendo-o conforme estipulado pelo postulante na petição inicial.

Estando o feito em ordem, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO

A controvérsia nos autos gira em torno da negativa do plano de saúde Amil Assistência Médica Internacional S.A. em custear o medicamento Xospata 40 mg – 84 comprimidos (Hemifumarato de Gilteritinibe), essencial para o tratamento de Leucemia Mieloide Aguda do autor, José Fabiano Holanda de Sousa, quando em vida, sob o argumento de que o referido medicamento não constava no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

O demandante alegou que tal negativa foi abusiva, uma vez que o tratamento foi prescrito por seu médico assistente e seria necessário para a preservação de sua vida, além de possuir registro na ANVISA.

Inicialmente, assento que ao caso concreto são aplicadas as regras de proteção ao consumidor, **nos termos das alterações advindas com a Lei 14.454/22**.

Na hipótese sub judice, comprovou a parte Autora que firmou com a Ré contrato de plano de saúde (ID nº 151650335) e que tinha indicação médica para realizar o tratamento medicamentoso com o Xospata 40 mg – 84 comprimidos (Hemifumarato de Gilteritinibe), conforme laudo médico de Id. 151650341.

Conquanto tal realidade, a empresa demandada sustentou que a negativa decorreu do fato de que o medicamento não constava dentro do rol de procedimentos obrigatórios da ANS para o tratamento da doença que se buscava combater, olvidando assim as garantias constitucionais e da legislação de que gozam os consumidores.

É que entende este Juízo, em consonância com a moderna jurisprudência e a recente Lei 14.454/22, que a circunspeção e seriedade da moléstia, passível de cobertura contratual como no caso, não pode ser aferida pela análise administrativa da empresa seguradora. Antes, é ilação a que apenas o médico assistente pode chegar, mediante a anamnese da situação em concreto.

Ademais, é pacífico o entendimento de que compete ao médico assistente determinar qual o tratamento que deverá ser aplicado ao paciente.

Neste viés, o Superior Tribunal de Justiça já apascentou que "*o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura*" (AgRg no REsp 1500631/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015).

Neste diapasão, denota-se claramente que a parte Autora estava a clamar, primacialmente, pelo respeito à saúde e à vida social digna, batendo por isso às portas do Judiciário, que ao longo dos anos vem se revelando o último refúgio e recurso dos aflitos e necessitados.

É certo que, se o contrato de saúde não exclui o tratamento para a doença, não pode o plano de saúde restringir o tipo de tratamento a ser utilizado, devendo ser obedecida a prescrição do médico responsável, a quem, conhecendo de perto o histórico do paciente, suas necessidades e os riscos envolvidos, compete exclusivamente decidir qual medida deverá ser aplicada, não cabendo ao plano interferir em tal avaliação, sob pena de frustrar a legítima expectativa do segurado em receber o tratamento mais adequado para a sua situação.

Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de ser abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.

De qualquer modo, é de se observar, a partir de rápida consulta ao site do governo federal, em aba específica da ANVISA, cujas publicações revelam que o medicamento em questão (Xospata – Hemifumarato de Gilteritinibe) se encontra devidamente registrado pela agência reguladora.

Neste sentido, a RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 540 alterou o ANEXO II DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465/2021 e o DUT Nº 64 determina a obrigatoriedade de custeio de TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CÂNCER. Veja-se:

SUBSTÂNCIALOCALIZAÇÃOINDICAÇÃO

Hemifumarato de Gilteritinibe	Leucemia Mielóide Aguda (LMA)	Em monoterapia, para o tratamento de pacientes adultos com leucemia mieloide aguda (LMA) recidivada ou refratária com mutação no gene FLT3 (tirosina quinase 3 semelhante à FMS), que não tenham sido submetidos a transplante de célula tronco hematopoiética (TCTH).

(sitio eletrônico: https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-da-sociedade/consultas-publicas/consultas-publicas-encerradas/publica-cp-no-96-tem-como-objetivo-receber-contribuicoes-para-a-revisao-lista-cobertura-planos-saude)

Por oportuno, cabe frisar que, se de um lado, a Lei nº 9.656/98 estabelece que, via de regra, a cobertura securitária não inclui o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar (art. 10, VI), de outro, a própria lei prevê exceções. Nestas, se inclui a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (art. 12, I, c) e cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar (art. 12, II, g).

Dessa forma, como dito, tem-se no caso em análise, portador de câncer em estágio avançado, para quem foi prescrito medicamento por médico especialista, cuja cobertura obrigatória se encontra prevista em legislação, sendo firme jurisprudência deste TJPE no sentido de garantir aos segurados nessa situação o fornecimento dos medicamentos prescritos, ainda que de uso domiciliar. Vejamos:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Antônio Fernando Araújo Martins , 593, 3º andar, RECIFE - PE - CEP: 50010-230 - F:() AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013516-05.2023.8.17.9000 AGRAVANTE:GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO:FELISMINO HUMBERTO BARBOSA RELATOR:DES. FERNANDO MARTINS Sexta Câmara Cível EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. ESTADO TERMINAL. MEDICAMENTO - Geilteritinibe (Xospata). NEGATIVA DE COBERTURA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO - Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o

paciente. Destarte, a disposição contratual apontada pela demandada para eximir-se da obrigação de fazer que lhe foi imposta é abusiva, porquanto não pode o plano de saúde fazer preponderar sua vontade sobre o tratamento recomendado pelo médico - A operadora não pode negar-se à cobertura de medicamento registado pela ANVISA e prescrito pelo médico da autora para tratamento de doença abrangida pelo contrato - No caso pessoa idosa, portadora de câncer em estágio avançado, para quem foi prescrito medicamento por médico especialista, cuja cobertura obrigatória se encontra prevista em legislação, sendo firme jurisprudência deste TJPE no sentido de garantir aos segurados nessa situação o fornecimento dos medicamentos prescritos, ainda que de uso domiciliar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que compõem a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade de votos,NEGAR provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Recife, de de 2024. DES. FERNANDO MARTINS - RELATOR cvs

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0013516-05.2023.8.17.9000, Relator: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 29/02/2024, Gabinete do Des. Antônio Fernando Araújo Martins)

Decerto, nos contratos de plano de saúde devem incidir os princípios da boa-fé, da confiança, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, não sendo legítimo à seguradora perceber por anos a contribuição do segurado para se esquivar da cobertura do tratamento indispensável à permanência da vida dele justamente quando do surgimento da doença.

Revela-se direito líquido e certo da parte Acionante, amparável na via ordinária, a cobertura do medicamento prescrito, seja porque abusivo o dispositivo negocial excludente, seja porque a assistência médica cristalizou a natureza necessária do medicamento.

Quanto ao pedido indenizatório, exsurge nitidamente que deve prosperar, nos termos os artigos 186, 927 e seguintes do Código Civil.

O dano e a relação de causalidade estão presentes não só pela negativa de vigência do contrato, mas pelo sentido de perda em relação à reparação da saúde em momento delicado da parte autora, objetivo primordial do procedimento médico irregularmente vetado.

Nesse diapasão, vejo que a prática intentada pela ré infringe o princípio constitucional da solidariedade e contraria os arts 4º e 6º, I, CDC, no que atine à proteção à vida e à saúde, bem assim o art. 14, §1º, pelo defeito na prestação do serviço, por não o fornecer da maneira esperada pelo consumidor de boa-fé.

Por certo, infligir a paciente - profundamente debilitado pela moléstia que lhe acomete - o ônus de vir a Juízo buscar a efetivação das suas prerrogativas, em detrimento da paulatina dor e sofrimento que se acha experimentando, significa vulnerar-lhe o bem-estar, carecendo da pronta compensação financeira.

Por suposto, "*embora geralmente o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada*" (STJ - AgRg no REsp 1.328.978/RS - Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - Julg. 13.11.2012 - DJe 20.11.2012)

O lesionamento, na espécie, não depende de prova de outros prejuízos ao patrimônio material, espiritual ou físico do postulante, porquanto se caracteriza *in re ipsa*.

Ademais, a jurisprudência mansa e pacífica do STJ assim vem entendendo em casos semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que a recusa injusta de plano de saúde à cobertura securitária enseja reparação por dano moral, ainda que se trate de procedimentos não emergenciais, uma vez que gera aflição e angústia para o segurado, o qual se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida, em virtude da enfermidade. Precedentes.

2. No caso, a recorrente teve negado o fornecimento de material necessário para a realização de procedimento cirúrgico, embora formulado oportunamente o requerimento perante a operadora do plano de saúde. Indenização fixada de acordo com as peculiaridades subjetivas do caso.

3. Na linha da jurisprudência do STJ, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no REsp 1372202/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

Em conclusão, tenho ser indevida a recusa da parte Ré em cobrir o fármaco nos termos solicitados pelo médico assistente, ressaltando que a necessidade era tamanha que o demandante veio a falecer no curso do processo, razão pela qual entendo que a demandada deve ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral, este arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) considerando a intensa extensão do dano suportado pela parte Autora e as condições pessoais das partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos iniciais para:

a) confirmar a liminar preteritamente concedida, condenando a Demandada ao custeio do medicamento Xospata 40 mg – 84 comprimidos (Hemifumarato de Gilteritinibe), solicitado pelo médico assistente, nos exatos termos do laudo médico, a ser convertido em perdas e danos no valor comprovadamente desembolsado, com juros e correção monetária a partir do evento, considerando o falecimento do demandante e a necessidade de aquisição do medicamento por outros meios, ante o não cumprimento da tutela de urgência no tempo determinado.

b) imputar a obrigação de indenizar a parte Postulante, em aspecto compensatório pelos sofrimentos e danos extrapatrimoniais, que valoro no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a repercussão e reprovabilidade do fato, bem assim a condição socioeconômica das partes litigantes (art. 944, CC), quantia a ser monetariamente corrigida pela tabela ENCOGE desde este *decisum* (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação (art. 405, CC).

Por fim, constatada a hipótese do art. 487, I, do Estatuto de Ritos, extingo o feito por sentença com incursão meritória, imputando à parte ré o ônus da sucumbência, representado pelas custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% do valor total da condenação, forte no art. 85, §2º, CPC/2015.

À diretoria para correção do polo ativo da presente ação, devendo constar **TATIANE GONÇALVES VIANA DE SOUSA e JOSÉ BENJAMIN FRANCISCO VIANA DE SOUSA**, qualificados em ID nº 162965967.

Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, não havendo manifestação, arquivem-se.

Recife-PE, data digitalmente certificada.

Ana Paula Costa de Almeida

Juíza de direito substituta

ds

Assinado eletronicamente por: ANA PAULA COSTA DE ALMEIDA
28/08/2024 16:15:24
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 180389353

24082816152389700000176009936

IMPRIMIR GERAR PDF